

## 版权所有©，不得随意转载

本篇内容综合刑法李翔老师和马寅翔老师的期末划重点内容整理。

最后附上了财产犯罪部分笔者自己的笔记（李翔班级）——因为李翔老师说这板块最重要。

红色部分为老师划重点强调部分。

绿色部分为必背部分。

每一板块前的宋体字为老师划重点强调的原内容（部分板块不太需要所以直接融合进内容）

华政法律学院 24010102016

## 考试

单选15题·1' 多选5题（以案例为主） 名词解释解答题案例分析

## 国家工作人员【93】

背国家机关工作人员 5+2+3（人大以立法解释扩大国家机关工作人员范围）

**第九十三条 【国家工作人员的范围】**本法所称国家工作人员，是指国家机关（**权利机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、参政议政机关政协、中国共产党各级委员会**）中从事公务的人员。

**国有公司、企业、事业单位、人民团体（财政纳入本级财政预算上海市法学会）中从事公务的人员**和国家机关、**国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体（在本级的民政局做过登记备案）从事公务的人员**，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。

→ 国有公司：

- 国家全资企业
- 国有控股企业：绝对控股（51%）；相对控股（多股东，国资占比较高）
- 国家出资企业（占比再少也是国家工作人员）

→ 村委会、居委会（群众自治组织）：

**在代表上一届政府实施职权时，当成国家工作人员。**

村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：

- （一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；
- （二）社会捐助公益事业款物的管理；
- （三）国有土地的经营和管理；
- （四）土地征用补偿费用的管理；
- （五）代征、代缴税款；
- （六）有关计划生育、户籍、征兵工作；
- （七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。

村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪、第三百八十四条挪用公款罪、第三百八十五条和第三百八十六条受贿罪的规定。

→ 扩大（3个）

（1）扩大1：虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权

**书记员**

（2）扩大2：在受国家机关委托代表国家机关行使职权的**组织**中从事公务的人员

**卫生健康委员会（国家机关）授权卫生委职权，那在卫生委工作中从事公务的人员是国家机关工作人员。**

（3）扩大3：依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员

## · 刑法分则体系依据什么来分10章节的，为什么要这样排列？（选择题）

十章：危害国家安全罪——危害公共安全罪——破坏社会主义市场经济秩序罪——侵犯公民人身权利、民主权利罪——侵犯财产罪——妨碍社会管理秩序罪——危害国防利益罪——贪污贿赂罪——渎职罪——军人违反职责罪

①（step 1）原则上依据同类客体（法益）分类。但并不是一章节中侵害的法益完全具有同等性，存在例外。

②（step 2）主要按照社会危害性大小：大体上由重到轻——第一章死刑占比最高；第二章是针对不特定多数人；第三章比较特殊，是为了突出经济建设的重要性，所以仅此于第二章；第四章虽然可判到死刑的多，但是并非这样计算（比如经济犯罪死刑被废除，是一种进步，体现以人为本）。但也存在例外，如醉酒驾驶放在第二章并不意味着就比后面的贪污贿赂社会危害性高。

罪名之间的内在联系：罪名从罪状中概括而来，从罪状的具体描述概括出本质的或主要的特征，因此罪名以罪状为概括的基础。比如120-126条主要就是讲恐怖主义、极端主义，只是根据不同的行为而做了区分。

· 单一客体★：一种犯罪行为只直接侵犯到一种具体社会关系。如非法拘禁罪

· 复杂客体★：一种犯罪行为同时侵害的客体包括两种以上的具体社会关系。例如绑架罪

→ 主要客体★：某一具体犯罪所侵害的复杂客体中程度较严重的，刑法予以重点保护的社会关系。主要客体决定该具体犯罪的性质，从而也决定该犯罪在刑法分则中的归属。例如，把抢劫罪列入侵犯财产罪中。

→ 次要客体★：某一具体犯罪所侵害的复杂客体中程度较轻的，刑法予以一般保护的社会关系，也称辅助客体。它是立法者在确定某一具体犯罪构成时也要同时予以保护的另一种具体社会关系。对于具有复杂客体的犯罪来说，除主要客体外，次要客体也是犯罪构成的必要要件，对于定罪量刑也有决定作用。例如，抢劫罪与抢夺罪的区别在于：抢劫罪既侵害他人财产权利，又侵害他人人身权利；而抢夺罪只侵害他人财产权利，不侵害他人人身权利。

→ 随机客体：在某一具体犯罪侵害的复杂客体中可能由于某种机遇而出现的客体，也称随意客体、选择客体。一般情况下，随机客体往往是加重刑事处罚的原因和依据。例如非法拘禁罪，侵害的主要客体是他人的人身自由权利，如果非法致人重伤、死亡时，就危害到他人的健康权利、生命权利。随机客体也属于复杂客体的一种，但与主要客体、次要客体不同的是主要客体、次要客体是某些犯罪的必备要件，而随机客体仅仅是选择要件，可能出现也可能不出现。一旦出现，只影响量刑，不影响定罪。

刑法修正主要以修正案行使，但是也不是绝对的，还有「补充规定」。

## 罪状 (选择题)

(1) 简单罪状：以高度抽象的语言进行描述。如第232条故意杀人罪，表述为“故意杀人者”。

(2) 叙明罪状：非常详细地将行为人的所有构成要件要素全面的描述出来。如《刑法》第305条【伪证罪】在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。「“的”字之前规定了所有构成要件要素」

(3) 引证罪状★★★：（刑法条文与条文的关系）立法者为了防止刑法条文的重复，在描述一个罪状的时候，运用引用式的表述，去参照刑法中的其他条款。

《刑法》第115条【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪】放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

【失火罪、过失决水罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪、过失以危险方法危害公共安全罪】过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。”

(4) 空白罪状★★★：（刑法与其他法律的关系）在刑法当中对犯罪构成要件不做表述，而是去看前置法律的法律规范。

刑法是“保障法”的地位。比如数据安全法、网络安全法，而在刑法中如果要写相应罪名，作为保障法不可能将其全部罗列，所以会按照“违反…法”的句式来引用。

## · 法条竞合和想象竞合的区别以及对法条竞合 (论述题·背背)

注意：包容竞合和交叉竞合概念是李翔老师在描述该论述题时着重强调的，用作分析的理论。小马没有强调该理论，故非李翔老师班上的学生可以在“法条竞合的适用规则”处直接看书本p369的两句话简化作答，并对第二原则的例子进行适当更改/重新选择便于理解，但是注意一定一定要背例子。

### 一、法条竞合

法条竞合是指一个犯罪行为同时符合数个法条规定，在法律适用上发生重合，只能选择适用其中一个法条，排斥其他法条适用的情况。

法条竞合的特征有：①行为人实施了一个犯罪行为，而不是数个犯罪行为②行为人实施的行为仅有一个犯罪构成，但却被规定在数个法条之中③只能选择一个法条适用，即选择数个法条中的一条定罪处罚，而排斥其他法条的适用

法条竞合的适用规则是：（1）处断原则一是特别条款优于普通条款。此时特别条款被包容于普通条款，范围比普通条款小——被称为“包容竞合”。比如滥用职权罪和徇私枉法（滥用司法裁判权）罪是典型的法条竞合，前者是一般法条（因为其法条中表述“本法另有规定的，依照规定”），而后者则是特殊法条。（2）当法条中相互包容，即产生“交叉竞合”时，基于罪刑均衡的需求，出现第二原则：重法优于轻法。如招摇撞骗行为类型被诈骗包容，诈骗范围更加宽泛。但是诈骗罪对象是财产性利益，但招摇撞骗对象不限于财产性利



益。即诈骗罪的手段比招摇撞骗宽泛，但是对象比财产性利益小。当行为同时满足招摇撞骗罪和诈骗罪时，应在两者之中选择重法。

## 二、法条竞合与想象竞合

同时构成其他犯罪的xxx，此时可能构成法条竞合也有可能是想象竞合。竞合在手段上、主体上、对象上都有可能产生。

具体而言，想象竞合是一种动态上的概念（一个行为触犯数个罪名）；而法条竞合是静态分析法条关系，分为包容竞合和交叉竞合。

## · 公共安全和人身、财产权利的关系（论述题）

公共安全就是人身权利和财产权利，只不过是特定多数人的权利。

公共安全，是指不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产安全。其包含两方面内容：一是安全性的范围具有广泛性，不仅包含人身安全、财产安全，还包括秩序安全，从而使安全的含义大大超出了分则其他各章的意义。其不仅可以物化为物质性对象，还可以表现为非物质性对象。二是安全内容的广泛性受到一定的限制。即本章的安全内容表现为公共性，针对的是涉及社会安全的犯罪行为，即不特定多数人的安全。对其他个人安全等不表现为公共安全的内容则不属于本章的犯罪客体。

（危害公共安全是指故意或过失地实施危害不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产安全的行为。）危害公共安全罪有时表现以侵害生命健康的安全为主，有时表现为侵犯财产的安全为主，还有时两者兼备。这和侵犯人身权利罪以及侵犯财产罪有共同之处。但是它们的区别也是明显的，后者可能造成的损失是有局限性的，是以特定人和特定范围的公私财物为对象的，其行为对象是不可替代的，而且不能属于重大的具有公共性的私有财产；而前者①对象不特定②行为不可控。换句话说。危害公共安全的行为一经实施，不论行为人是否意识到，他们在本质上都能在一定条件下引起许多人的伤亡，公私财产的广泛破坏，或者形成对广大群众生命财产安全的严重威胁。这也是此类犯罪之所以是危险性最大的一类普通刑事犯罪的根本原因。

## 以危险方法危害公共安全罪

114兜底性条款（非刑法分则第二章的兜底条款）“以危险方法危害公共安全”要素：（1）方法要客观上危险，无论主观认识错误（2）程度很严重，与法定刑配置要匹配（法定刑很高）：和防火、爆炸、决水……看司法解释有哪些情形

马路飙车的行为区分是危险驾驶罪还是以危险方法危害公共安全罪。

连续杀人不能构成以危险方法危害公共安全罪，而是故意杀人的连续犯。

第一百一十四条 【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪之一】放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处3年以上10年以下有期徒刑。

第一百一十五条 【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪之二】放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

## 一、概述

是指以防火、决水、爆炸、投放危险物质之外的危险方法危害公共安全的行为。

本罪属于具体危险犯：法官需要根据具体的案件事实，判断行为人的行为是否对不特定多数人的身或财产安全造成了威胁。

本罪的适用范围：放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的危险方法+危险性质相当的+不可控性+足以对公共安全造成具体威胁【具有高度危险性，行为人一旦实施就无法对其波及的范围加以控制，因而在短时间内危及不特定多数人的身或财产安全。】

## 二、构成

1. 对象：公共安全，即不特定多数人的生命、健康或者重大财产的安全

2. 行为：行为人以防火、决水、爆炸、投放危险物质**相当的方法**危害公共安全。如驾车撞人、设电网、将载客的车开下悬崖、用机枪向人群扫射等。可由作为或者不作为构成。

(1) “相当的方法”★ ★ ★：

① “其他危险方法”是指使用与放火、决水、爆炸、投放危险物质的危险性相当的危险方法

② 行为同时符合其他犯罪构成要件的，如果不违背罪刑均衡原则，应认定为其他犯罪，如在公共场所开枪射击。

最高人民法院《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：“使用爆炸、投毒、设置电网等危险方法破坏野生动物资源，构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪或者非法狩猎罪，同时构成刑法第一百一十四条或者第一百一十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”

依照司法解释及判例，下列情形应定本罪：

① 破坏矿井通风设备，危害公共安全的

② 在多人通行的场所私拉电网，危害公共安全的

③ 在火灾现场破坏消防器材，危害公共安全的

④ 在高速公路上逆向高速行驶的

⑤ 邪教组织人员自焚，危害公共安全的

⑥ 醉酒驾车，肇事后继续驾车冲撞，造成重大伤亡结果的

⑦ 驾车冲撞、碾轧、拖拽、剐蹭民警或者挤别、碰撞正在执行职务的警用车辆，危害公共安全的

⑧ 故意造成突发传染病病原体传播，或者有传播危险的

⑨ 盗窃、破坏生产、生活、人员聚集场所的窨井盖，危害公共安全的

⑩ 危害公共安全的自杀行为

《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》 故意传播新型冠状病毒感染肺炎病原体，具有下列情形之一，危害公共安全的，依照刑法第114条、第115条第1款的规定，以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚：

1. 已经确诊的新型冠状病毒感染肺炎病人、病原携带者，拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗，并进入公共场所或者公共交通工具的；

2. 新型冠状病毒感染肺炎疑似病人拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗，并进入公共场所或者公共交通工具，造成新型冠状病毒传播的。

(2) “危险”★ ★ ★：方法要客观上危险，无论主观认识错误

(3) “尚未造成严重后果的，处3年以上10年以下有期徒刑”：说明尚未造成严重后果的，**不是构成未遂而仍然是既遂**。本罪是危险犯。

3. 主体：已满16周岁

注：14-16周岁怎么办：按照八大最行中的故意杀人和伤害行为定。

4. 责任要素：故意才能构成此罪，包括直接或者间接故意。

**【区】危险驾驶罪or以危险方法危害公共安全罪**

危险驾驶罪的“危险”：类似于抽象危险犯，只要有一个举动即可。三更半夜醉酒驾驶（按目前司法解释，甚至连危险驾驶罪都可能构成不了）

以危险方法危害公共安全罪的“危险”：要能造成具体现实的危险。人多的广场上开车冲撞

**【注】**持刀连续杀人不能构成以危险方法危害公共安全罪，而是构成故意杀人的连续犯。（一刀只能杀一个人，所以危险形成性是可控的）

## 破坏交通工具罪 & 破坏交通设施罪

做到盗窃窃取性和破坏型财产犯罪时，注意留意犯罪对象，看是不是和公共安全有关联，进而看是不是构成这两个罪名（如翘起铁轨卖掉）。此时产生竞合，择一从重，这时候选择危害公共安全类犯罪，因为有死刑（侵犯财产罪没有死刑）。

公共性都是体现在足以使交通工具造成倾覆、毁坏的危险（危险犯）。正在使用的界定。

## 破坏交通工具罪

### 一、概述

破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生颠覆、毁坏危险，尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为。

### 二、构成

1. 对象：只能是正在使用中的火车、汽车、电车、船只、航空器等机动交通工具，即行为人的行为会导致不特定的多人轻重伤、死亡或者重大公私财产损害的交通工具（法益：公共交通运输安全）

(1) “正在使用中”：正在行驶或者飞行中，待用、备用的交通工具。

对已经生产完毕并经检验合格即将投入营运、正在运营暂时停靠的汽车，可以理解为正在使用中；对已经报废、检修厂检修的汽车，不能视为正在使用中。

2. 行为：破坏正在使用中的以上五种交通工具，已经造成或足以造成交通工具倾覆、毁坏危险的行为。

(1) 破坏可以是有形破坏，也可能是外表完整无损，但是损坏其功能。

破坏尚未修好的汽车不构成破坏交通工具罪，因为本身车的性能就不完备，也没有被认定为性能完备。

汽车修理工故意不修好汽车构成，因为此处车子的性能在交付后被认定为性能完备。

(2) 危险：具体危险，即在具体场合下对交通工具的破坏具有发生倾覆、毁坏的现实可能性。

在起飞前或者降落后打开安全门对飞机只构成延误不构成倾覆的危险。

飞行过程中擅自打开安全门构成，存在倾覆的危险。

3. 主体：一般主体

4. 责任要素：故意，包含直接故意和间接故意。

### 三、认定

## 1. 本罪 vs 破坏交通设施罪

行为对象不同。毁坏移动铁路信号装置、拆卸铁轨、在铁轨上放置造成颠覆的危害物等应该被认定为破坏交通设施罪

交通设施罪责任要素可以为过失

## 2. 本罪 vs 盗窃罪、故意毁坏财物罪

核心：是否足以危害公共安全。

step 1 判断行为的对象是否是正在使用中的交通工具。

step 2 判断侵害导致的后果的程度是否达到严重危害公共安全。如果只是盗窃或毁坏交通工具上的一般设备或附属设备、辅助设施，不足以危害交通安全的，应以盗窃罪或者故意毁坏财物罪论处；如果行为人盗窃交通工具重要机件直接危及交通运输安全，足以造成交通工具倾覆、毁坏的，则属于想象竞合，择一从重，这时候选择危害公共安全类犯罪，即破坏交通工具罪，因为有死刑（侵犯财产罪没有死刑）。

## 劫持航空器罪处罚条款中范围问题

《刑法》第121条 犯劫持航空器罪，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑；致人重伤、死亡或者使航空器受到严重破坏的，处死刑。

★★★注：“致人重伤、死亡”在主观上不仅包括过失，也包括故意。即在劫持航空器中故意杀人，也被认定为劫持航空器罪，而非故意杀人罪。

## 盗窃枪支罪主观成立前提

盗窃枪支罪成立的前提是：故意，即要达到明知盗窃的对象是枪支的程度。

## 交通肇事罪 (全部重点，要记构成)

注意 构成要件 和 司法解释

违反交通管理法规；一人死亡或者三人重伤，30万元。

★★司法解释★★：（1）转化故意杀人或故意伤害（把被害人带离肇事地点，造成被害人死亡）；

（2）交通肇事罪主体范围扩大化，包含行人、乘车人（其交通肇事罪成立要件必须是发生交通事故后即行为人违章在先，指使逃逸，导致被害人得不到救助死亡-死亡与逃逸有因果关系）、机动车所有人、承包人

第一百三十三条 【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处3年以上7年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处7年以上有期徒刑。

### （一）构成

1. 对象（法益：交通运输安全）

2. 行为：因违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者公私财产遭受重大损失。

#### （1）场所：



①只能是公路和水上交通事故（不包括航空和铁路）②★必须是公共交通安全管理范围内的公路、城镇道路以及水路上。如果是机关、厂矿、学校、封闭的住宅小区等没有实行公共交通安全管理的范围内，因使用交通工具致人伤亡或者造成财产损失，构成犯罪的，应分别依照重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪或者过失致人死亡罪定罪处罚。

(2) ★“重大交通事故”：

根据2000年11月最高法《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，“重大交通事故”是指具有下列情形之一的情况：

A. 死亡1人或者重伤3人以上，负全部或主要责任的；【人员伤亡】

B. 死亡3人以上，负事故同等责任的；【人员伤亡】

——★AB出现这些特定数量的伤亡事故后，能否成立交通肇事罪，关键在于行为人是否要承担事故的全部或主要责任。

C. 造成公私财产直接损失，负事故全部或主要责任，无能力赔偿额在30万元以上的。

“直接财产损失”：事故当场造成的财产损失，而不包括一些次生的损失（间接损失）

D、交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪论处：

A. 酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的

B. 无驾驶资格驾驶机动车辆的

C. 明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的

D. 明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的

E. 严重超载驾驶的

F. 为逃避法律追究逃离事故现场的

3. 主体：一般主体，一般是驾驶人。

并不特指驾驶人，也可以是车主、乘车人等

4. 责任要素：对违章可能是明知故犯，但对发生的后果必须是过失。（否则不能定此罪）

(二) 认定

★司法解释★：

(1) 转化作为的故意杀人（把被害人带离肇事地点，造成被害人死亡）；

(2) 交通肇事罪主体范围扩大化：包含行人（如行人违反交通运输管理法规，导致车辆紧急变道造成伤亡，应认定行人构成交通肇事罪）、乘车人（其交通肇事罪成立要件必须是发生交通事故后即行为人违章在先，指使逃逸，导致被害人得不到救助死亡-死亡与逃逸有因果关系）、机动车所有人、承包人。

1. 司法解释中的交通事故“责任”认定模式

认定交通肇事罪时，主要依据“行为之交通违章程度”认定“事故责任大小”，从而认定是够成立犯罪以及罪责的轻重。

2. 本罪与非罪的界限

交通肇事罪定罪处罚标准有二：（1）事故造成结果的大小（2）根据各方违章程度“认定或者分配”应该承担的事故责任。

3. 关于共犯的认定

交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。

4. 关于指使他人违章驾驶的行为责任

单位主管人员、机动车辆所有人或者机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故的，以交通肇事罪定罪处罚。

#### 5. 关于交通肇事后隐藏、遗弃被害人致其死亡、伤残的罪责

构成不作为故意杀人/故意伤害罪定罪处罚。

行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃致使被害人无法得到救治而死亡或者严重残疾的，应当分别依照《刑法》第232条、第234条第2款的规定，以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。

#### 6. 交通肇事罪 vs 重大责任事故罪等过失犯罪的界限

是否发生“实行公共交通的范围内”。如果在实行公共交通管理范围外，因为违反工作责任规章等造成重大损害，应当认定为重大责任事故罪。

#### (四) 处罚

犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

交通肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处3年以上7年以下有期徒刑。

“交通运输肇事后逃逸”，是指行为人违反交通运输管理法规，在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为。

“其他特别恶劣情节”，是指交通肇事具有下列情形之一的：死亡2人以上或者重伤5人以上，负事故全部或者主要责任的；死亡6人以上，负事故同等责任的；造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在60万元以上的。

(1) “逃逸”：行为人违反交通运输管理条例，发生交通事故后，**为了逃避法律追究**而逃跑的行为。——以交通肇事行为构成犯罪为前提。

因逃逸致人死亡的，处7年以上有期徒刑。

(2) “因逃逸致人死亡”：行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。**(核心：逃逸行为与死亡之间存在因果关系)**

最高法院在《刑事审判参考》1116号邵大平交通肇事案的指导案例中明确指出：“因逃逸致人死亡”的认定，不以逃逸前的交通肇事行为构成犯罪为前提”。**(交通肇事罪不是逃逸致人死亡的前提，即在无法证明肇事时将被害人撞至重伤的程度情况下，也可以认定逃逸致人死亡)**

★★★人在现场找人顶包，构成交通肇事罪的逃逸致死中的“逃逸”。

## 危险驾驶罪

行为类型要掌握133四种类型

和交通肇事罪关系：**危险驾驶罪（抽象危险犯）是交通肇事罪（实害犯）的前端[预防刑法观]**，前者法定刑低于后者。

133构成其他犯罪的从一重处——包含交通肇事罪

### 一、概述

第一百三十三条之一 **【危险驾驶罪】**在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：

(一)追逐竞驶，情节恶劣的；

(二)醉酒驾驶机动车的；

(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；

(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。

机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。  
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

在道路上驾驶机动车，有《刑法》第133条之一规定的危险驾驶情景之一的行为。

## 二、构成

1. 对象（法益：道路交通安全管理制度以及行人人身、车辆及其他公共设施的安全）

2. 行为★★★★：

（一）追逐竞驶，情节恶劣的；

（二）醉酒驾驶机动车的；

（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；

（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。

3. 主体：一般主体

4. 责任要素：故意。

## 三、认定

1. 本罪与非罪的界限

较轻情节：短距离挪车等

2. ★★★【联系】与交通肇事罪（背背背）

两罪侵犯的客体都是公共安全。

两者的区别在于：（1）犯罪性质上：危险驾驶罪是危险犯；交通肇事罪是实害犯。

（2）行为类型上：危险驾驶罪只有特定行为才能构成（追逐竞驶、醉酒驾驶、校车或旅客运输中超员、超速行驶、违规运输危险化学品的行为）；交通肇事罪泛指所有违章行为。

（3）成罪条件上：危险驾驶罪危险只要符合刑法规定的一些特定的危险行为类型就可以构成本罪；交通肇事罪要求必须造成重大事故或者人员损伤财产的实害结果。（4）主观方面：危险驾驶罪是针对行为的故意；交通肇事罪是针对结果的过失。（5）刑罚上：危险驾驶罪的处罚为拘役并处罚金；交通肇事罪的处罚为基本刑处3年以下有期徒刑或者拘役，有逃逸或者其他特别严重情节的处3年以上7年以下有期徒刑，逃逸致人死亡的，处7年以上有期徒刑。对比起来，前者比后者处刑更轻，因为不强调造成实害结果。

两者的联系在于：从[预防刑法观]来看，危险驾驶罪（抽象危险犯）是交通肇事罪（实害犯）的前端。

3. 醉驾认定

（1）醉驾 vs 交通肇事罪

（2）醉驾 vs 以危险方法危害公共安全罪

4. 本罪罪数形态 ★★★

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

即133构成其他犯罪的从一重处，尤其注意包含交通肇事罪（考试）。

## 故意伤害罪

身体健康：包含（1）肉体健康（2）器官功能的完整性

（3）精神伤害？——通常不可以，最多构成侮辱罪。但是持续的辱骂造谣使得对方造成物质性的神经器官功能的损坏，构成想象竞合，定故意伤害罪。

## 组织出卖人体器官罪

看一眼 234之一增加的罪名

核心：被组织者同意，若不同意可能定义故意杀人/伤害罪

第二百三十四条之一 【组织出卖人体器官罪】组织他人出卖人体器官的，处5年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

未经本人同意摘取其器官，或者摘取不满18周岁的人的器官，或者强迫、欺骗他人捐献器官的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

违背本人生前意愿摘取其尸体器官，或者本人生前未表示同意，违反国家规定，违背其近亲属意愿摘取其尸体器官的，依照本法第三百零二条的规定定罪处罚。

核心：被组织者同意，若不同意可能定义故意杀人/伤害罪

→ 未经本人同意摘取其器官，或者摘取不满18周岁的人的器官，或者强迫、欺骗他人捐献器官——定故意伤害/杀人罪。

→ 违背本人生前意愿摘取其尸体器官，或者本人生前未表示同意，违反国家规定，违背其近亲属意愿摘取其尸体器官——定盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰罪

## 强奸罪

即使订婚后还是可以构成强奸。

## 非法拘禁罪

本身的法律条文要注意

特别是都是被害人死亡的不同认定区别：结果加重、法律拟制、数罪并罚

### 一、概述

第二百三十八条 【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。

国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

概述：指以非法拘禁或者以其他方法，非法剥夺他人人身自由的行为。

\* 刑法中一旦规定有“非法”，就一定有对应的“合法性行为”。自由刑都是剥夺人身自由的，像管制是限制人身自由

\* 剥夺权利必须依照法定程序。

### 二、构成

#### 1. 主体：一般主体

年满16周岁，精神正常的人。

#### 2. 行为：采用扣押或者其他方法，非法剥夺他人人身自由

(1) 方法：不论扣押的理由是否合法，只强调权利和程序。



只要客观上剥夺他人人身自由，就是非法拘禁。所以手段像故意杀人罪一样行为无法穷尽，举出典例“扣押”。

剥夺自由不是非要体现在暴力手段，对于被害人心理上实施强制力也属于。

(2) “自由”：对于被害人、加害人**都认识到的现实具体人身自由**。如果是一种未来的、可能的、抽象的自由，则不包括。**比如在对方睡觉时候锁门，在对方醒之前打开门——如果对方没醒就是没有意识到，那这种自由是一种可能的，不是具体现实的，不能认定为非法拘禁；但是如果对方中途醒来，意识到自己被锁，就可以认定为非法拘禁。【实害犯】**

(3) **立案标准**：**累计24小时以上，如果有暴力则不受24小时限制。**

★★★：

① 从重处罚（侮辱、殴打行为）

② 结果加重犯（致人重伤、死亡的）★

③ 转化犯（**使用暴力**致人重伤死亡的）★

属于法律拟制，将不符合故意杀人时拟制为故意杀人/故意伤害罪。

【区别】犯意转化

如果构成非法拘禁罪，又产生了故意杀人/故意伤害的故意，则要非法拘禁和故意杀人/伤害数罪并罚。

【小结】出现非法拘禁致人重伤死亡的思路

[1]结果加重犯[2]转化犯[3]数罪并罚（犯意转化）

④ 主体身份从重（国家机关工作人员）

3. 对象：有现实的、具体的行动意思或者能力的人（侵犯法益：**现实自由**）

该对象标准根据侵害法益的现实自由说倒退可得。

4. 罪责：故意

### 三、认定

1. 为催收债务非法拘禁的认定（p580）★：

(1) 非法拘禁行为催收非法债务：若达到非法拘禁罪的标准，**定非法拘禁罪**（法定刑相对偏高），不定催收非法债务罪。

(2) 索取不存在债务：**定绑架罪**。（没有债务=勒索财物）

## 绑架罪

1. 注意目的问题：分为**绑架勒索型**（获得财产性利益）；**绑架人质型**

2. 特别在绑架勒索型中要考虑，如【区】**拐卖妇女儿童罪**以出卖、勒索财物为目的拐卖婴幼儿，不同目的不同处罚。绑架以绑架为目的，拐卖妇女儿童罪以出卖为目的。

### （一）概述

第二百三十九条【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

概述：指以勒索财物为目的绑架他人，或者处于政治性或者其他目的绑架他人作为人质，或者以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的行为。

## （二）构成

1. 行为：以【绑架勒索型】勒索财物为目的绑架他人的，或者【绑架人质型】绑架他人作为人质的。

【区】绑架勒索型&拐卖妇女儿童罪

绑架以绑架为目的，拐卖妇女儿童罪以出卖为目的。

2. 对象：一般-他人；偷盗婴幼儿-婴幼儿

3. 罪责：故意

## （三）法定刑

《刑罚修正案（九）》对于绑架案的修改

➤ 修改前：以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。犯前款罪，致（说明主观罪过是过失）被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并没收财产

➤ 修改后：犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的处无期徒刑或者死刑，并没收财产。

## 3. 非法拘禁和绑架的关系（论述题）

（1）行为主体、客体、具体行为差别。

（2）不仅仅是区别。还有关系：绑架以剥夺人身自由为前提，而剥夺人身自由以违背他人意志为前提。没有非法拘禁的行为不能定绑架。

【关系】绑架罪与非法拘禁的（背背背）

（1）关系：绑架罪中绑架的行为当然的包含了非法拘禁，但是绑架罪是一个重罪，所以对非法拘禁不再另行评价。（想象竞合，从一重处罚）

（2）差别：①犯罪目的不同：如果行为人是以勒索财物为目的，就应该构成绑架罪；如果行为人以索取债务等为目的，就应构成非法拘禁罪②侵犯客体不同：非法拘禁侵犯的只是他人的人身自由权，属单一客体；绑架罪不仅侵犯他人人身权利，而且侵犯他人财产权利，属于复杂客体③被害人与犯罪人的关系不同：非法拘禁罪中犯罪人与被害人之间存在着债权债务关系（包括法律不予保护的债权债务关系）；绑架罪中犯罪人与被害人之间不存在债权债务关系。

## 拐卖妇女儿童罪

拐卖儿童罪 vs 拐骗儿童罪——直接看法条找区别。14周岁以下，骗不具有卖。

【240】【拐卖妇女、儿童罪】拐卖妇女、儿童的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：

（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；

（二）拐卖妇女、儿童3人以上的；

（三）奸淫被拐卖的妇女的；

（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；

- (五)以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
- (六)以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
- (七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；
- (八)将妇女、儿童卖往境外的。

拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

【262】 【拐骗儿童罪】 拐骗不满十四周岁的未成年人，脱离家庭或者监护人的，处5年以下有期徒刑或者拘役。

#### 1. 不同

(1) 犯罪目的不同：拐骗儿童罪，主要是为了收养或者使唤；而拐卖妇女、儿童罪是贪图钱财、贩卖牟利。如果拐骗儿童是为了贩卖牟利，则应当以拐卖妇女、儿童罪论处。

(2) 犯罪对象不同：14周岁以下，骗不具有卖。

2. 偷盗婴幼儿行为的性质认定：行为人如果以勒索财物为目的偷盗婴幼儿，应以绑架罪论处；如以出卖为目的偷盗婴幼儿，应以拐卖儿童罪论处；如以收养为目的偷盗婴幼儿的，应以拐骗儿童罪论处；如以索取债务为目的偷盗婴幼儿的，应以非法拘禁罪论处。

#### 3. 【区】与收买被拐卖妇女、儿童罪

(1) 拐卖妇女儿童罪：有数个行为只构成一个罪名

(2) 收买被拐卖的妇女、儿童罪：可能构成多个罪名

《刑法》第241条 【收买被拐卖的妇女、儿童罪】 收买被拐卖的妇女、儿童的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚（强奸罪）。

收买被拐卖的妇女、儿童，非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的，依照本法的有关规定定罪处罚。

收买被拐卖的妇女、儿童，并有第二款、第三款规定的犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

(3) 如果是先收买然后将其卖掉：只构成拐卖妇女儿童罪一个罪名

## 侮辱罪

★ 必须针对特定个体，不能是针对特定区域的人（地域黑不构成侮辱罪）。

## 重婚罪

★ 构成上以为故意~~故意~~为成罪的前提

## 遗弃罪

遗弃的地点对故意杀人还是遗弃罪产生重要影响。

【区】与故意杀人罪

· 遗弃罪：（核心：救助概率高）只是为了逃避抚养义务，并不希望或者放任被害人死亡，将生活不能自理的被害人死亡，将生活不能自理的被害人弃置在福利院、医院、派出所等单位或者广场、车站等行人较多的场所，希望被害人得到他人救助的。

· 故意杀人罪：（核心：死亡概率高）希望或者放任被害人死亡，不履行必要的抚养义务，致使被害人因缺乏生活照料而死亡，或者将生活不能自理的被害人带至荒山野岭等人迹罕至的场所扔弃，使被害人难以得到他人救助的。

## 入户抢劫

八种加重情节第一项就是入户抢劫

重要要素：以抢劫为目的。区别于其他目的与在户抢劫（在房子里临时起意抢劫）

入的理解、户的理解、入户目的的要求；结合案例尤其防止“以xx名义”的问题

## 抢劫罪

### 一、概述

第二百六十三条 【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：

- （一）入户抢劫的；
- （二）在公共交通工具上抢劫的；
- （三）抢劫银行或者其他金融机构的；
- （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
- （五）抢劫致人重伤、死亡的；
- （六）冒充军警人员抢劫的；
- （七）持枪抢劫的；
- （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

1. 概述：以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行夺取他人财物的行为

2. 司法解释

- 《关于审理抢劫案件具体适用法律若干问题的解释》
- 《关于抢劫过程中故意杀人案件如何定罪问题的批复》
- 《关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》

### 二、构成

1. 主体：一般主体（14-16，包含形式责任能力人）

2. 行为：复行为犯（暴力、胁迫及其他手段的行为+强行夺取公私财物的行为）

（1）“暴力”：无上限，包含剥夺他人生命权（区别于强奸罪的“暴力”）；有下限，要能够足以抑制被害人反抗（作为重罪，要严格解释）。

（2）“胁迫”：只能是以暴力为内容的胁迫，不能是精神上的胁迫「否则可能构成敲诈勒索等罪名」。且该暴力具有现时现实转化的可能性。

（3）其他手段：不能不知不敢反抗的状态

（4）关于“手段”与“取财”的因果关系：暴力胁迫其他手段要与取财有因果关系，即被害人将财物留在当场是基于前面的暴力胁迫其他手段产生恐惧被迫而留下的。比如行为人抢劫但是被害人基于同情给钱，此时不构成抢劫罪。



(5) 取财的表现形式：不重要。更重要的是因果关系。

3. 对象：人身及财物

4. 罪责：故意

### 三、转化抢劫问题（背条款和构成）★★★★

第二百六十九条 【转化的抢劫罪=事后抢劫】犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

关于三个适用条件的理解——三者**必须兼备**：

#### （一）前提是行为人首先实施了“盗窃、诈骗、抢夺罪”的罪行

1. 此时是罪行还是罪名？——是犯罪（既遂）or **故意+行为**？

不是罪名，而是**罪行**。不是要完全满足犯罪构成要件要素，只要有该罪的故意和行为即可。

2. 特殊的盗窃、诈骗、抢夺是否适用？——此时是特指“盗窃、诈骗、抢夺罪”还是整个“盗窃、诈骗、抢夺”罪名体系？

“特殊”的意思即有盗窃的行为但是不认定为盗窃罪，而是其他犯罪。此时是否可以转化？——（目前）不转化

#### （二）手段是当场使用暴力或者以暴力相威胁

· 现场、抓捕过程

· 程度要求

· 对象（不一定是失主，也不要求对方认识到行为人的先前行为）

· 排除对自身使用暴力或者体现威胁

例：甲盗窃后被他人发现，甲以加害自己威胁他人不要对其实施抓捕

#### （三）目的是为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭证据

### 四、抢劫罪的加重情节研究

1. 入户抢劫的理解（**属于加重情节**）★——标准：要与家庭生活密切相关，与外界**相对隔离**如：牧民的帐篷、渔民的船只、租房都可以被认定为“户”

(1) 【讨论】商铺中前面经营，后面住人；在白天作为经营场所，晚上作为生活场所，算“户”吗？

前面抢劫的不是，后面抢劫的是；抢劫白天抢劫就不是，晚上抢劫就是。

(2) 相对隔离**不考虑合法或者非法**，只认定实然状态。违章搭建不影响“户”的认定

(3) 入户★：必须是**非法性目的**，不一定是犯罪目的，不一定要具有抢劫等目的。

→ ★如果是**获得同意合法进入**（如访友办事后在户临时起意抢劫），在屋内进行抢劫的话，不属于入户抢劫。

（★此处注意区分“以xx名义，实则抢劫”的入户目的，以抄水表的名义让主人开门，不属于“合法”入户，即主人不能有认识错误）

2. 在公共交通工具上抢劫的认定——以公共交通工具的私行人员作为抢劫对象（**对象加重**，而非地点加重）

(1) 由此排除小型公共交通工具。如出租车

(2) 由此可以解决**拦公共交通工具**然让乘客下来抢劫

3. 抢劫银行和金融机构的认定——以**银行或者金融机构的资金**作为抢劫对象（**对象加重**，而非地点加重）

4. 多次抢劫或者抢劫数额巨大的

5. 抢劫致人重伤死亡的
6. 冒充军警人员抢劫的理解
  - (1) 若就是军人或者警察，那么是从重情节，不是加重情节。
  - (2) “冒充”：行为人会以某种方式向被害人显示身份
  - (3) 保护本国军警的声誉，所以冒充他国军警不构成。
7. 持枪抢劫的理解
  - (1) “持”即可，不用使用
  - (2) 真枪
  - (3) 同样，在法律上不和非法持枪数罪并罚，直接将持枪作为抢劫罪的法定刑升格条件。
8. 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资

## 虚假链接案

给人虚假链接的最高人民法院指导性案例。一种构成盗窃罪，一种构成诈骗罪。

【指导案例27号：臧进泉等盗窃、诈骗案】

裁判要点：行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际通过预先植入的计算机程序窃取财物构成犯罪的，以盗窃罪定罪处罚；虚构可供交易的商品或者服务，欺骗他人点击付款链接而骗取财物构成犯罪的，以诈骗罪定罪处罚。相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条

核心：被害人有没有认识到自己实际在处分财产。行为人只有处分1元的意识没有处分几十万的意识。

裁判理由：盗窃是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为；诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。对既采取秘密窃取手段又采取欺骗手段非法占有财物行为的定性，应从行为人采取主要手段和被害人有无处分财物意识方面区分盗窃与诈骗。如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是秘密窃取，诈骗行为只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付财物的，就应当认定为盗窃；如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是诈骗，被害人基于错误认识而“自愿”交付财物，盗窃行为只是辅助手段的，就应当认定为诈骗。

## 盗窃罪 ★★★

盗窃的类型：公私财务数额较大；入户；多次盗窃；携带凶器；扒窃

记构成的认定和依据（案例析题） ★★★

### 一、概述

第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

概述：以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大或多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃行为。

## 二、构成

1. 行为：秘密窃取 ★★★公私财务数额较大、入户盗窃、多次盗窃、携带凶器盗窃、扒窃
2. 对象：公私财物（财物所有权或占有）
3. 罪责：故意（不存在过失）

## 三、注意事项（“占有”）★★★

1. 非法占有（不法所有）目的：非法占有目的由“（对所有人或占有人）排除意思★★★”与“（对财物）利用意思”构成。前者重视的是法的侧面，后者重视的是经济的侧面，二者的机能不同。

其中利用意思方面：

- （1）利用意思不限于遵从财物原先设定的用途加以利用

\* 包括满足行为人特定的心理需求

- （2）不能认为行为人具有归还的意思就排除行为人非法占有目的

即，非法占有目的不一定是永久的非法占有目的。

员工为了向老板索要工资，将老板的车秘密开走，说“你什么时候发工资，什么时候我把车还你”。——构成盗窃。

“我把你的xx物拿走，等xx时间还给你”——为了避免这种情况出现，应当认定构成犯罪。

### 2. 占有问题

**核心：主客观相统一，更侧重事实占有。**

刑法上占有重在事实上的支配，占有意思对事实的支配的认定起补充作用。只要求他人对其事实上支配的财物具有概括的、抽象的支配意识，既包括明确的支配意思，也包括潜在的支配意识。

具体分述如下：

- （1）只要是在他人的事实支配领域内的财物，即使他人没有现实地握有或监视，也属于他人占有。

高中同学乙到甲家里来玩，为了表示对甲在高中帮助的感谢，乙带了一万来，并在甲不知情的情况下塞到了沙发底下。过几天丙来甲家，偶然发现并拿走了一万元。考虑到甲家为甲事实支配的领域，即使甲没有现实地握有或监视，也构成甲的占有。丙即为盗窃。

典型·出租车遗留财物 须视为出租车司机占有，不能视为遗失物

- （2）虽然表面上处于他人支配领域之外，但存在可以推知由他人事实上支配的状态时，也属于他人占有的财物。

校园骑自己自行车到教学楼下，没上锁，他人将自行车拖走。存在可以推知由他人事实上占有。

小情侣去公园赏樱花，把汽车没锁放在路边，他人将汽车开走并说“今天在路边捡到了一辆汽车”。

【保洁捡到一百多万黄金】甲登机排长队，队伍旁边有一个垃圾桶。甲拎着黄金包就随手放在垃圾桶旁边且没有走一步放一步。保洁人员即将包拎走，后来才发现黄金。不能认为所有人和包有距离了，就失去了占有。一般观念中可推知，财物由行为人所占有。

- （3）在特定场所，所有人、占有人在场的，原则上应认定为所有人、占有人占有。

下课去洗手间，将手机留在座位上。认为手机仍然由所有人占有，即使没有现时随身携带。

【二万六到底谁占有】被害人到银行存钱二万六千，夫妻也去银行办业务。被害人单子填好后，钱放在桌子上。后来想起来时钱就没有了。过程中原来是，一老太太看到了全程，顺手就将钱装在口袋里，后携老伴快速离开。

(4) 主人饲养的具有回到原处能力或习性的宠物，不管宠物处于何处，都应认定为饲主占有。

(5) 即使原占有者丧失了占有，但当该财物转移为建筑物的管理者或者第三者占有时，也应认定为他人占有的财物。

典型·遗留于酒店的东西被后住者拿走 管理者属于事实上的支配，因为酒店的房间具有排他性，即要么是后来住户要么就是酒店工作人员。所以后来者将前面的人的财物拿走，属于盗窃。

【区别】侵占：事实上的支配—排他性

华政教学楼里面忘了带走自己的包。此时华政教学楼的教室属于开放性的，随意出入的。此时财物需要评价为无人占有/原所有人失去占有，此时拿走财物的人只能评价为侵占。

(6) 存款占有归属，存款人占有债权。

(7) 数人共同管理某财物，而且存在上下主从关系时，下位者不占有该财物。此时下位者容易构成盗窃。

保姆偷走主人的东西。仍然认为该财物由主人占有。

销售将店里的衣服直接拿走。仍然认为该财物由店老板所有，所以构成盗窃而不是侵占。

出车站时有人帮忙拿行李拿到车上。只是辅助者，并不占有该财物。

(8) 行为人受他人委托占有某种封缄的包装物时，封缄物整体由受托人占有，但内容物为委托人占有。受托人不法取得封缄物整体的，成立侵占罪；取出其中的内容物的，成立盗窃罪。

(9) 死者的占有主要由三种情况：一是行为人以抢劫故意杀害他人后，当场取得他人财物（抢劫罪）；二是行为人出于其他目的地杀害他人后，产生非法占有他人财物的意思，取得死者的财物；三是无关的第三者从死者身上取得财物。后两种行为认定为侵占罪。

所有权说：故意杀人罪+盗窃罪（遗产继承人所有）

占有说：故意杀人罪+侵占罪（遗产继承人所有，但并不占有。所以此时的财物属于无人占有的状态）

## 四、盗窃罪中需要深入研究的问题

### 1. 秘密性不是其必要构成要件要素（学说）。

原来：（通说）相对（财产占有者和所有人/财产管理人）的秘密性

（财产占有者和所有人）只有所有人没有看见，其他人在公交车上都看见了/监控排的清清楚楚小偷的扒窃。此时仍然认为构成盗窃罪。

此时强调秘密性是必要构成要件要素，公然的视为抢夺。

现学说：秘密性不是其必要构成要件要素——重新划分了盗窃罪和抢夺罪之间的界限。

将抢夺罪对象范围限缩，只有行为人对物使用暴力造成人身伤害可能性时才构成抢夺。（其他评价为公然盗窃）如公然抢女生身上的项链。（抢劫：必须对人身有暴力行为）

· 秘密性的争论：刑法客观主义&刑法主观主义



- 1) 刑法客观主义：犯罪以行为为中心，重点在于分析行为本身对法益的侵害程度。
- 2) 刑法主观主义：犯罪不仅是一种外在行为，还涉及行为人的内心状态和主观意图。  
· 但由于，刑法必须综合考虑行为的客观后果和行为人的主观动机。  
· 所以，根据刑法主观主义：
  - 1) 秘密窃取的方式反映出行为人的主观恶性和人身危险性相对较小。
  - 2) 抢夺罪的典型特征：行为人当着被害人的面，公然夺取财物，在这一过程中，行为人已经预料到，被害人会反应过来，并进行反抗，但是他并不畏惧，甚至做好了被害人反抗的准备。抢夺罪的行为人主观恶性更大，具有更高的人身危险性。
  - 3) 相比之下，盗窃罪的行为人选择秘密窃取的方式，目的在于避免被害人发现。盗窃罪的行为人在主观上更倾向于规避直接对抗，不希望引发被害人的注意。
  - 4) 盗窃罪必须具有秘密性是合理的。

## 2. 盗窃公私财物，数额较大：

我国刑法立法是**定性+定量**。【比较法】美国是立法定性，司法定量。

【延伸】故意中的认识因素包不包含对于罪量的认识：（李翔）**对于罪量有认识可能性** 否则排除故意。\* 注为“可能性”，不是确定的数额认识。

此时会产生的结果：受教育程度越高，注意义务越高，（李翔）这才是公平的。

| 则在盗窃罪中，行为人必须对犯罪数额具有认识可能性。

【**农民工到北京培训基地随便摘了两串葡萄价值12万6千块**】此时行为具有盗窃性质，但是缺乏对于财物价值的认识，所以出罪。

★注意：盗窃违禁品也算盗窃罪。而盗窃违禁品不是以数额，而是以**情节**。

## 3. 价值：

数额要求或者使用价值要求（身份证等）

价值要求：考虑**使用价值**及对**特定人**的价值。

4. **窃取行为**是排除他人对财物的支配，**建立新的支配关系**的过程。窃取的手段与方法没有限制，即便使用了欺骗方法，但如果该欺骗行为并没有使对方基于认识错误处分财产的，仍然**成立盗窃罪**

5. **多次盗窃**，是指**二年内三次**以上盗窃。

A. “次”应根据客观行为认定，时间、地点、被害人要素

B. **不以每次成立盗窃行为既遂为前提，也不要求每次盗窃行为均成立盗窃罪**  
(更加注重行为人的主观恶性，没有入罪要求)

6. **入户盗窃**。★★★**合法入户后盗窃的，不宜认定★**；**非法入户，即使入户后才产生盗窃犯意的，也应认定为盗窃罪★**。

强调**入户非法性**，没有入罪要求，因为行为上侵害了另外的法益。

5. **携带凶器盗窃**的。注意与第267条第2款（携带凶器抢夺）区别。

没有数额的入罪要求，要找其他的入罪要素，即“**携带凶器**”。

→ **携带凶器盗窃，后被发现，对对方进行捅刺**——构成**故意伤害罪★**，不构成抢劫罪。

6. **扒窃要素**：公共场所；他人随身携带的财物；值得刑法保护。

**行为人主观恶性会更大**。

→ “随身”：随身≠贴身。**放在身边携带也属于随身**。

## 五、盗窃罪的认定

1. 盗窃罪与盗窃枪支、弹药、爆炸物罪

## 2. 盗窃罪与信用卡诈骗罪

【讨论】为什么盗窃信用卡并使用认定为盗窃罪而不认定为信用卡诈骗罪？

法律拟制，不能推广到抢劫、诈骗、抢夺等其他犯罪。

## 3. 盗窃罪既遂、未遂的认定标准——行为人取得（占有）了财物（行为人的占有与占有人的失去占有一般是并行的），且达到一定数额

结合具体案件本身进行综合评价：

柜台用调包方式偷戒指，但是未出商场被逮住。戒指本身形态容易控制，理解为离开柜台盗窃既遂。

偷电瓶车过程中被发现，被追赶。此处不宜评价为盗窃既遂。

## 抢夺罪（携带凶器抢夺）（案例分析）（记记记）

携带凶器抢夺

- 客观上“凶器”：性质上的凶器：枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械；用法上的凶器：从使用方法来看，可能用于杀伤他人的物品，如菜刀、棍棒、石块等。
- 行为人将随身携带凶器有意加以显示、能为被害人察觉到的，直接适用抢劫罪；行为人携带凶器抢夺后，在逃跑过程中为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，适用抢夺罪转化抢劫罪。
- 主观上：①抢夺前为了使用而携带②处于其他目的而携带，在现场意识到所携带的凶器进而实施抢夺。

## 侵占罪★★★★

普通侵占 & 脱离占有物

脱离占有物中：侵占和盗窃的区别就在于归谁占有——行为人本人占有就是侵占，他人就是盗窃。

要注意“占有”的界定

记构成的认定和依据（案例分析题）★★★★

### 一、概述

- 概述：指以非法占有为目的，将代为保管的数额较大的他人财物占为己有，拒不退还或者将他人的遗忘物、埋藏物占为己有，数额较大，拒不交出的行为

### 二、构成

- 行为：已然持有（合法持有）+非法占有  
【区别】和盗窃罪最大的区别：盗窃罪中，财物还处于行为人的占有★★★★
- 对象：代为保管的他人之物，埋藏物、遗忘物
- 罪责：故意

### 三、侵占罪的基本问题

- ★★★★【普通侵占】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，或者【遗忘物/埋藏物侵占——侵占脱离占有物】将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的行为。包括普通侵占和侵占脱离占有物。
  - 普通侵占一般发生在熟人之间，所以设置为“告诉才处理”
  - 侵占脱离占有物

- 【区别】遗失物 vs 遗忘物——一般以财物所有人的记忆力作为判断标准。

遗失物无法想起；遗忘物可以想起。

区分目的：限制处罚范围。遗失物不考虑刑法处罚。

- (李翔) 有无必要对遗忘物和遗失物进行区别？

不论是否存在委托关系，只要非行为人所有，就要受到刑法处罚：

宽泛遗忘物定义：非经他人本意而失去控制，偶然（即不是基于委托关系）由行为人占有或者占有人不明的财物。

底层逻辑：君子社会。刑法理论根据：评价行为人行为应当从行为人角度分析，不能从被害人角度分析记忆力——行为人是否会定罪，完全取决于被害人记忆力的好坏。

- 埋藏物：埋藏于地下，所有人不明或应由国家所有的财物。

(3) “拒不退还，拒不交出”：说明要求权利人至少有一次权利的主张过程。限制了处罚范围

“非法占为己有”与“拒不退还”的关系：后者是对前者的强调或者补充说明，即将自己占有的他人财物变为自己所有的财物。

【例外】如果行为人将财产处分——遵从财物的用法，例如出卖、赠予、消费、抵偿债务等，就表明其“非法占为己有”。如果单纯毁坏则不能成立本罪。| 即如果代为保管的财物不可替代，而作为保管人以所有人自居消费使用。此时可以认定为：明知道消费后财物灭失，直接认定为“非法占为己有”。

- “拒”的理解：不可将行政权直接用司法权替代。

2. 代为保管——事实上的支配和法律上的支配，以财物所有人与行为人之间存在委托关系为前提

3. 基于不法原因而委托给付的财物，能否成为本罪的对象。

4. 窝藏或者代为销售的赃物能否成为侵占罪的对象

5. 侵占行为的理解——取得行为

#### 四、侵占罪疑难问题探讨

1. 侵占罪与盗窃罪的区别——判断财物由谁占有，是否脱离占有

2. 行为人认识错误

例如，行为人将他人占有的财物误认为他人的遗忘物而非法占为己有；本来是遗忘物，行为人以为是他人占有的财物而非法占为己有

3. 由于侵占罪的对象难以排除国家、集体所有的财产，立法上的亲告罪设置似有疑问：告诉才处理包括控告与起诉。

---

## 侵犯财产罪罪名一览✅ (综合全部的侵犯财产罪罪名具体内容见最后)

罪名都是重要的，都考。

抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、侵占罪

## 挪用公款罪

挪用的行为方式：（1）非法活动没有数额、盈利活动数额较大、其他活动数额较大超过三个人未还

（2）归个人适用（区别于挪用特定款物罪），本身要记

**第三百八十四条 【挪用公款罪】**国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的，是挪用公款罪，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

### 一、认定

1. 行为：挪用公款归 个人使用 ★★★

（1）必须要有 使用（不光挪还得用，才能构成）

不具非法占有目的【区别于贪污罪】

（2）必须 归“个人” ★★★（利己性）【区】挪用特定款物：

有所扩大：

① 供本人或其他自然人使用

②（单位1）以 个人名义 挪用给单位使用

③（单位2）个人决定 以单位名义挪用给单位使用

（3）“使用”的用途 ★★★：

① 非法活动：无数额和时间的要求；数罪并罚

② 盈利活动：有数额较大要求，无时间要求

③ 其他活动：有数额较大要求，挪用超过三个月

（4）“公款”：不一定是物，还可以是 救灾物资 等。

（5）数罪并罚问题：因挪用公款 索取、收受贿赂（源头是受贿，后端是挪用公款）构成犯罪的，挪用公款进行 非法活动构成其他犯罪 的，依照数罪并罚的规定处罚

（6）“挪用公款数额巨大不退还的”：不是主观上不想退换（否则就是贪污了），而是 客观上不能退还——结果加重（挪用公款不具有非法占有目的，主观上不想退换就是具有非法占有目的，系贪污）

时间要素：一审宣判前不能退还

（7）挪用公款罪的转化犯

对下列行为，应以贪污罪（本质：非法占有目的）论处（可推定有非法占有目的）：

① 携带挪用的公款潜逃的

② 挪用公款后采取虚假发票平账、销毁有关账目等手段，使所挪用的公款已难以反映在单位财务账目上，且没有归还行为的。

③ 截取单位收入不入账，非法占有，使所占有的公款难以反映在单位财务账目上，且没有归还行为的。

④ 有证据证明行为人有能力归还所挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的。

### 二、挪用公款罪的疑难问题

（1. 要注意挪用公款三种用途的使用条件，未达到不作为犯罪。★★★）

2. 挪用公款归还个人欠款的，应当根据产生 欠款的原因，分别认定属于挪用公款的何种情形。

赌债——产生原因：赌博——非法活动——挪用公款从事非法活动。



挪用去买股票——产生原因：股票——挪用公款进行盈利活动

3. 对挪用公款罪的用途认定，应根据客观的使用性质予以判断。

要看**最终**在客观上用在哪里。

4. 行为人挪用公款分别用于非法活动、盈利活动与其他活动，用于某项活动的公款数额未达到该罪的定罪标准，但挪用公款的**总额达到某项定罪标准**的，应当如何处理？

非法活动本身具有不法性，所以其入罪标准应该更低，则三种用途的标准不可能统一，统一则缺乏实质公正。

#### 【案例】

甲前后两次都不达到，总额达到。

乙挪用从事非法活动7000元、从事盈利活动25000元，总体达到了其他活动的数额入罪标准。

实践中观点一：都不定罪

观点二：都定罪

→反驳：存疑有益于被告人原则

李翔：存疑有益于被告人原则应当是事实存疑（此处事实不存疑），法律存疑是正常的。

对非法数额的评价是更负面的，不能把其他活动的数额用在非法数额的累积计算上，这对行为人是~~不利~~的，也从性质上改变了非法活动；相反，如果把**非法活动数额用于盈利活动数额是可以**的。

不能乙非法活动25000元，丙5000元，前后都不定罪。

## 巨额财产来源不明罪

属于兜底性的，如果能查清上游犯罪则只处罚上游犯罪，而**不是数罪并罚**。

## 受贿罪

· 关键在**权钱交易（权力交易，用财产性利益）**，不论形式。

· 注意三种行为方式：索贿（包括勒索贿赂）、被动收受、斡旋受贿

### 一、认定（记记记，案例分析）

国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者**非法收受他人财物为他人谋取利益的行为**。

1. 三种行为方式：索贿（包括勒索贿赂）、被动收受、斡旋受贿（**不是利用本人职务便利，而是利用本人的职务影响通过其他人的职务便利**）

2. “财物”：具有价值的可以交易的有体物、无体物以及财产性利益。

→“财产性利益”：（游贿案件）行为人请国家工作人员出去旅游的行为，如果被接受，也应当认定为受贿；

\* 房子、汽车不要求实际过户

3. “为他人谋利”（**司法解释**）：国家工作人员**许诺**为他人谋利，而不能要求是实实在在地谋取了利益（**不需要“着手”**）（联合国反腐败公约中存在：许诺、实施、实现三种，完成一种都属于）。这里的许诺既可是明示的，也可以是暗示的。

**在司法中的推定：行为人明知他人有请托事项，没有拒绝就视为同意。**

4. 索取或收受贿赂：并不限于行为人将贿赂直接据为己有，而是**包括使请托人向第三者提供贿赂**的情形

雅贿：溜须拍马情商式的行贿。“（一个破瓷器）哎呀我买这个用20万你还亏了”

## 二、解释

### 1. 解释

【解释的扩大化】（一）实际或者承诺为他人谋取利益的；（二）明知他人有具体请托事项的；（三）**履职时未被请托，但时候基于该履职事由收受他人财物的**——“事后”的理解。

采购部经理选A公司，事后A公司来感谢他给钱，经理知道为什么给钱的

【解释的刑事推定】**特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后未退还或者上交的**，应当认定国家工作人员具有受贿故意（第16条第2款）

→“特定关系人”：近亲属（父母、配偶、子女）+有共同利益关系的情人

是指“知道还不退还上交”，以此推定受贿。但是本人若产生错误认识，客观没有上交退还，那也不能从结果推定。

→“收受他人财物，**及时**上交或者退还”：“及时”是指**行为人缺乏受贿故意，不是时间的概念**

· 为什么要特定设置这个“出罪路径”：中国会出现收钱≠受贿的情况，如饭不得不吃但没有受贿故意。

2. 【财物】包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。后者的犯罪数额，以实际支付或者应当支付的数额计算。

3. 【故意的认定】国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，**将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的**，不影响贪污罪、受贿罪的认定，但量刑时可以考虑。

4. 【解释的政策化】（感情投资）**国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。**（第13条第2款）

· 人情往来与受贿的关系：行为人对财物价值认知可能性（结合行为人的教育背景、社会背景、社会认知）：若对物的客观价值认知缺乏可能性，不能单独基于数额定罪。**字画**——只要求行为人有**概括认知**，也不要求具体数额（2）现实情况礼物价值可能不对等-限制性解释思路：数额限制在**同一类对象主体**之间。司法实践中这种**不按刑事犯罪按照违纪**。

## 行贿罪

两个重要要素：（1）谋取不正当利益（受贿没有）（2）行贿罪特别从宽处罚条款（什么样情况下可以从轻或者减轻，什么情况可以减轻或者免除）

**第三百八十九条** 【行贿罪】为谋取**不正当利益**，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

**第三百九十条** 【对犯行贿罪的处罚】对犯行贿罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

有下列情形之一的，从重处罚：

- (一) 多次行贿或者向多人行贿的；
- (二) 国家工作人员行贿的；
- (三) 在国家重点工程、重大项目中行贿的；
- (四) 为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
- (五) 对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；
- (六) 在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；
- (七) 将违法所得用于行贿的。

行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

## 注意表述（名词解释）



### 1. 交通肇事罪

【133】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处3年以上7年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处7年以上有期徒刑。

### 2. 负有照护职责人员性侵罪★★★

对于幼女负有特殊职责的人员与幼女发生性关系的，以强奸罪论处。

对已满十四周岁的未成年女性负有特殊职责的人员，利用其优势地位或者被害人孤立无援的境地，迫使未成年被害人就范，而与其发生性关系，以强奸罪定罪处罚。

(1) 注：不存在“违背被害人意志”的考量

(2) 特殊主体：对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员

特殊职责的判定：不仅仅一定要具有形式上的职责，而是要从实质性的角度判断行为人对于被害人有没有优势或者支配地位。

目的：强化行为人的注意义务。

### 3. 事后抢劫★★★

【269】【转化型抢劫罪】犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

### 4. 挪用公款罪

国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为。

### 5. 非法拘禁罪

【238】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。

犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。

国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

#### 6. 以危险方法危害公共安全罪★★★

放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全的行为。

#### 7. 绑架罪★

以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的行为。

#### 8. 侵犯公民个人信息罪★★★

指违反国家有关规定，向他人出售、提供公民个人信息，或者以窃取、其他方法非法获取公民个人信息，情节严重的行为。

#### 9. 侵占罪★★★

以非法占有为目的，将代为保管的数额较大的他人财物占为己有，拒不退还或者将他人的遗忘物、埋藏物占为己有，数额较大，拒不交出的行为

## 过失致人死亡罪作为普通条款✓

滥用职权/玩忽职守罪致人死亡、交通肇事罪致人死亡、重大责任事故罪——都是过失，均死亡结果作为犯罪成立条件。而233过失致人死亡是作为普通条款，当其他条款也规定了过失致人死亡，适用其他特别条款。

1. 与非法拘禁罪竞合★

2. 与虐待罪竞合★

3. 与交通肇事罪竞合

## 注意“以受贿论”、“以贪污论”、“明知道有损他人名誉…

## 以捏造并散布论“等等”✓

本质上和原来的犯罪构成有一定差距，如果不做这种“以…论”就无法定罪，属于刑法中的特别规定  
笔记中找这些讲得多的”以…论“

### 1. 奸淫幼女罪

《刑》第236条 【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。

【奸淫幼女罪】奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。

强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：

- (一) 强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
- (二) 强奸妇女、奸淫幼女多人的；
- (三) 在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
- (四) 二人以上轮奸的；
- (五) 奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
- (六) 致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

### 2. 负有照顾职责人员性侵罪

《性侵意见》第21条 对于幼女负有特殊职责的人员与幼女发生性关系的，以强奸罪论处。



对已满十四周岁的未成年女性负有特殊职责的人员，利用其优势地位或者被害人孤立无援的境地，迫使未成年被害人就范，而与其发生性关系，以强奸罪定罪处罚。

修法原理：从刑事政策的角度，强化行为人的主体义务。

- (1) 本罪保护的法益：未成年人（女性）身心健康
- (2) 不存在“违背被害人意志”的考量
- (3) 特殊主体：对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员

特殊职责的判定：不仅仅一定要具有形式上的职责，而是要从实质性的角度判断行为人对于被害人有没有优势或者支配地位。

目的：强化行为人的注意义务。

### 3. 侮辱、诽谤罪

2013年9月2日最高人民法院第12届检察委员会第9次会议通过，2013年9月10日公布，2013年9月10日起施行

第一条 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“捏造事实诽谤他人”：

(一) 捏造损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布的；

(二) 将信息网络上涉及他人的原始信息内容篡改为损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，或者组织、指示人员在信息网络上散布的；

明知是捏造的损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，情节恶劣，以“捏造事实诽谤他人”论。

行为：“散布”可以被认定；如果是“捏造”，则不用强调特意散布，因为其本身就包含“散布”

### 4. 交通肇事罪共犯的认定

交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。

### 5. 贪污罪

第三百八十二条 【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。

与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处（注意规定）。

### 6. 公共财产

第九十一条 【公共财产的范围】本法所称公共财产，是指下列财产：

- (一) 国有财产；
- (二) 劳动群众集体所有的财产；
- (三) 用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。

在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。

## 7. 国家工作人员

**第九十三条 【国家工作人员的范围】**本法所称国家工作人员，是指国家机关（权利机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、参政议政机关政协、中国共产党各级委员会）中从事公务的人员。

国有公司、企业、事业单位、人民团体（财政纳入本级财政预算上海市法学会）中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体（在本级的民政局做过登记备案）从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。

## 8. 受贿罪

**第三百八十五条 【受贿罪】**国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

**第三百八十七条 【单位受贿罪】**国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。

前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。

**第三百八十八条 【受贿罪】**国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

## 9. 行贿罪

**第三百八十九条 【行贿罪】**为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

## /以下在刑法中的表述不一定为“以…论”，但均为转化犯

### 10. 挪用公款罪的转化犯

对下列行为，应以贪污罪（本质：非法占有目的）论处（可推定有非法占有目的）：

- ① 携带挪用的公款潜逃的
- ② 挪用公款后采取虚假发票平账、销毁有关账目等手段，使所挪用的公款已难以反映在单位财务账目上，且没有归还行为的。
- ③ 截取单位收入不入账，非法占有，使所占有的公款难以反映在单位财务账目上，且没有归还行为的。
- ④ 有证据证明行为人有能力归还所挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的。

### 11. 非法拘禁罪转化故意杀人/故意伤害：

非法拘禁，使用暴力致人重伤死亡的。

- ① 从重处罚（侮辱、殴打行为）

② 结果加重犯（致人重伤、死亡的）

③ 转化犯（使用暴力致人重伤死亡的）

属于法律拟制，将不符合故意杀人时拟制为故意杀人/故意伤害罪。

### 【区别】犯意转化

如果构成非法拘禁罪，又产生了故意杀人/故意伤害的故意，则要非法拘禁和故意杀人/伤害数罪并罚。

### 【小结】出现非法拘禁致人重伤死亡思路

[1]结果加重犯[2]转化犯[3]数罪并罚（犯意转化）

## 12. 虐待被监管人员罪转化犯问题：

如果虐待行为导致被监管人重伤或者死亡，将转化为故意伤害/杀人罪

## 13. 私自开拆、隐匿、弃毁邮件、电报罪转化犯问题：

邮政工作人员，转化为盗窃罪的情形——“犯前款罪而窃取财物的，依照本法第二百六十四条的规定定罪从重处罚。”

## 14. 转化抢劫

第二百六十九条 【转化的抢劫罪】犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

关于三个适用条件的理解：

### （一）“犯盗窃、诈骗、抢夺罪”的理解

1. 此时是罪行还是罪名？——是犯罪（既遂） or 故意+行为？

不是罪名，而是罪行。不是要完全满足犯罪构成要件要素，只要有该罪的故意和行为即可。

2. 特殊的盗窃、诈骗、抢夺是否适用？——此时是特指“盗窃、诈骗、抢夺罪”还是整个“盗窃、诈骗、抢夺”罪名体系？

“特殊”的意思即有盗窃的行为但是不认定为盗窃罪，而是其他犯罪。此时是否可以转化？——目前认为不转化。

### （二）当场使用暴力或者以暴力相威胁

- 现场、抓捕过程
- 程度要求
- 对象（不一定是失主，也不要求对方认识到行为人的先前行为）
- 排除对自身使用暴力或者体现威胁

例：甲盗窃后被他人发现，甲以加害自己威胁他人不要对其实施抓捕

### （三）窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭证据

三者必须兼备

## 15. 抢夺罪的转化犯问题

携带凶器抢夺转化为抢劫罪

· 上述凶器的认定：（1）在性质上就可以被评价为凶器 管制刀具 （2）在用法上可以被评价为凶器 板砖（性质属于建筑材料）

· 上述携带的认定：行为人为抢夺时候使用而携带，或者在抢夺时意识到自己携带（不是客观状态）。而不是仅仅认定为“携带”的客观状态。

## 16. 交通肇事罪转化故意杀人或故意伤害：

把被害人带离肇事地点，造成被害人死亡

## 有关题型

概括性命题方式

以下贪污贿赂犯罪的说法，以下哪些说法是错误的？

多选题以重点的四章进行命题

人身、危害公共安全、财产、人身

名词解释20'

答题要求：只要答1句话，原则上就是送分的。

论述题（就是拿每一个大章节的名字来说，如危害公共安全罪与侵害公民人身权利罪与财产权利犯罪的关系）

公共安全就是人身权利和财产权利，只不过是特定多数人的权利。

考查评论性——开放性论述题

案例分析题（不唯一答案，言之有理即可）——集中在财产犯罪

构成侵占or盗窃的依据：法律规定（刑法文本有规定）、司法解释、法学理论看法条

华政法律学院 24010102016



## 【附录笔记】

### 第三讲 侵犯财产罪（第五章）★

关于本罪的法益：财产所有权及其他本权（如占有，也需要被保护）

关于财产侵犯罪的对象问题↓

#### 关于“财物”的内涵和外延

- 财物是否限于有体物？不限。无体物比如煤气
- 财物是否仅限于有价值之物？不限。判断“有价值”是从法律上评价，比如淫秽物品、毒品等。但是此处不限于有价值之物，比如盗窃淫秽物品也构成盗窃。
- 财物是否仅限于动产？不限。
- 财物是否包括违禁品？包括。包括国家专有的，包括任何人都不能拥有所有权的。
- 财物是否包括葬祭品？包括。“葬祭品”不是指文物——有专门文物保护罪名体系，此时指的是比如随葬品。这种放弃所有权是附有条件的，这种附条件放弃所有权刑法依然要保护。
- 财物是否包括人的身体？包括。当人体器官等和人体分离前，是人体健康的问题；分离之后，就具有人体属性。
- 财物是否包括财产凭证？部分包括。将财产凭证限定在 具有价值、不记名、不挂失。比如购物券。
- …… 财物是否包括虚拟物？如游戏号

## 第二十八章 抢劫罪

### 一、概述

第二百六十三条 【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：

- （一）入户抢劫的；
- （二）在公共交通工具上抢劫的；
- （三）抢劫银行或者其他金融机构的；
- （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
- （五）抢劫致人重伤、死亡的；
- （六）冒充军警人员抢劫的；
- （七）持枪抢劫的；
- （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

1. 概述：以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行夺取他人财物的行为

2. 司法解释

- 《关于审理抢劫案件具体适用法律若干问题的解释》
- 《关于抢劫过程中故意杀人案件如何定罪问题的批复》
- 《关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》

## 二、构成

1. 主体：一般主体（14-16，包含形式责任能力人）
2. 行为：复行为犯（暴力、胁迫及其他手段的行为+强行夺取公私财物的行为）
  - (1) “暴力”：**无上限**，包含剥夺他人生命权（区别于强奸罪的“暴力”）；**有下限**，要能够足以抑制被害人反抗（**作为重罪，要严格解释**）。
  - (2) “胁迫”：只能是以**暴力为内容**的胁迫，不能是精神上的胁迫「**否则可能构成敲诈勒索等罪名**」。且该暴力具有**现时现实转化**的可能性。
  - (3) 其他手段：**不能不知不敢反抗**的状态
  - (4) 关于“手段”与“取财”的**因果关系**：暴力胁迫其他手段要与取财有因果关系，即被害人将财物留在当场是基于前面的暴力胁迫其他手段产生恐惧被迫而留下的。**比如行为人抢劫但是被害人基于同情给钱，此时不构成抢劫罪。**
  - (5) 取财的表现形式：不重要。更重要的是因果关系。
3. 对象：人身及财物
4. 罪责：故意

## 三、转化抢劫问题

第二百六十九条 【转化的抢劫罪】犯盗窃、诈骗、**抢夺罪**，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

关于三个适用条件的理解：

### （一）“犯盗窃、诈骗、抢夺罪”的理解

1. 此时是罪行还是罪名？——是犯罪（既遂）or **故意+行为**？  
不是罪名，而是罪行。不是要完全满足犯罪构成要件要素，只要有该罪的故意和行为即可。
2. 特殊的盗窃、诈骗、抢夺是否适用？——此时是特指“盗窃、诈骗、抢夺罪”还是整个“盗窃、诈骗、抢夺”罪名体系？  
“特殊”的意思即有盗窃的行为但是不认定为盗窃罪，而是其他犯罪。此时是否可以转化？  
Eg：盗伐林木罪等  
首先，林木可以被评价为财物。其次，刑法没有评价其为盗窃罪，而是将其放在破坏生态环境资源的罪名中。  
**观点一（传统观点）**：此处有一个“罪”字，所以就是特指这三种罪。  
**观点二（李翔）**：

对比下列案例：

- 甲盗伐他人房前屋后自留地零星树木后被发现，适用暴力将被害人打成轻伤
- 乙盗伐成片林木后被发现，适用暴力将被害人打成轻伤

专门司法解释认为，“盗伐他人房前屋后自留地零星树木”为盗窃罪而不是盗伐林木罪。那么此处甲的行为就会被认定为抢劫，处以三到十年有期徒刑。

而此处乙“盗伐成片林木”构成盗伐林木罪（三年以下有期徒刑）而不是盗窃罪，后给其定为故意伤害罪为三年以下有期徒刑或拘役。此时法定最高刑只有六年。

此时就出现了非正义的结论，并不公平。说明传统解释思路有问题，必须重新寻找解释方法。

- 甲盗窃2000元后，被他人发现，使用暴力将被害人打成重伤。甲定抢劫罪，处10年以上有期徒刑。
- 乙原本打算盗窃，但是发现被害人后使用暴力并致被害人轻伤，取得2000元，出门后被他人发现，使用暴力，致被害人重伤。

乙：结论一：「犯意转化，从新意」抢劫罪+故意伤害罪（3-20年）；结论二：抢劫罪（269条）10年以上至死刑。

此时为了公平，对乙必须选择结论二，那么存在了抢劫转化抢劫的情况。

#### 14-16周岁

最高法态度：不转化（不定罪或者定故意伤害罪、故意杀人罪）

最高检：转化（定抢劫罪）

· 分歧的原因：

最高法从刑事政策处罚必要性角度考虑，其认为本质还是盗窃诈骗抢夺，而对于14-16周岁这些罪名没有处罚必要性。但是如果重伤/死亡，则是侵犯人身权益，此时定故意伤害罪/故意杀人罪。

最高检从法律解释的位阶——刑法的体系性角度考虑，根据《刑法》第267条第2款“携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定（抢劫罪）定罪处罚”。若有15岁丙携带凶器抢夺c，被发现后使用凶器将c打成轻伤；若有15岁乙只是抢夺，被发现后从路边拿一个凶器将被害人达成轻伤。（第269条中的“抢夺”没有限定带不带凶器）而此时按照最高法，乙就是不定罪，而丙要定抢劫罪，这是第一步不公平。进一步，“携带凶器抢夺”应该构成抢劫罪，但是如果携带凶器抢夺被发现后使用凶器打人按照最高法又不定罪了，无疑是在鼓励携带凶器抢夺人最好让人发现一下再打人就能不定罪了，这是第二步不公平。

实务中由于法院有后位优势，所以以法院为主要观点。

## （二）当场使用暴力或者以暴力相威胁

- 现场、抓捕过程
- 程度要求
- 对象（不一定是失主，也不要求对方认识到行为人的先前行为）
- 排除对自身使用暴力或者体现威胁

例：甲盗窃后被他人发现，甲以加害自己威胁他人不要对其实施抓捕

## （三）窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭证据

三者**必须兼备**

## 四、抢劫罪的加重情节研究

1. 入户抢劫的理解——标准：**要与家庭生活密切相关，与外界相对隔离**

如：牧民的帐篷、渔民的船只、租房都可以被认定为“户”

（1）【讨论】商铺中前面经营，后面住人；在白天作为经营场所，晚上作为生活场所，算“户”吗？

前面抢劫的不是，后面抢劫的是；抢劫白天抢劫就不是，晚上抢劫就是。

（2）相对隔离**不考虑合法或者非法**，只认定实然状态。**违章搭建不影响“户”的认定**

（3）入户：具有**非法性**即可，不一定要具有抢劫等目的。因为这样法律上可以不将非法侵入住宅罪和抢劫罪进行数罪并罚（“住宅”和“户”实质相同），就将入户非法性作为抢劫的法定刑升格条件。

2. 在公共交通工具上抢劫的认定——以公共交通工具的私行人员作为抢劫对象（对象加重，而非地点加重）
  - (1) 由此排除小型公共交通工具。如出租车
  - (2) 由此可以解决 拦公共交通工具然让乘客下来抢劫
3. 抢劫银行和金融机构的认定——以银行或者金融机构的资金作为抢劫对象（对象加重，而非地点加重）
4. 多次抢劫或者抢劫数额巨大的
5. 抢劫致人重伤死亡的
6. 冒充军警人员抢劫的理解
  - (1) 若就是军人或者警察，那么是从重情节，不是加重情节。
  - (2) “冒充”：行为人会以某种方式向被害人显示身份
7. 持枪抢劫的理解
  - (1) “持”即可，不用使用
  - (2) 同样，在法律上不和非法持枪数罪并罚，直接将持枪作为抢劫罪的法定刑升格条件。
8. 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资

## 第二十九章 盗窃罪

### 一、概述

第二百六十四【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

1. 概述：以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大或多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃行为。
2. 司法解释

《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体适用法律若干问题的解释》

《关于审理破坏森林资源刑事案件具体适用法律若干问题的解释》

《关于审理未成年人刑事案件具体适用法律若干问题的解释》

《关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》

### 二、构成

1. 行为：秘密窃取数额较大、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃
2. 对象：公私财物（财物所有权或占有）
3. 罪责：故意（不存在过失）



### 三、注意事项

1. 非法占有（不法所有）目的：非法占有目的由“（对所有人或占有人）排除意思”与“（对财物）利用意思”构成。前者重视的是法的侧面，后者重视的是经济的侧面，二者的机能不同。

其中利用意思方面：

(1) 利用意思不限于遵从财物原先设定的用途加以利用

\* 包括满足行为人特定的心理需求

(2) 不能认为行为人具有归还的意思就排除行为人非法占有目的

即，非法占有目的不一定是永久的非法占有目的。

员工为了向老板索要工资，将老板的车秘密开走，说“你什么时候发工资，什么时候我把车还你”。——构成盗窃。

“我把你的xx物拿走，等xx时间还给你”——为了避免这种情况出现，应当认定构成犯罪。

2. 占有问题

**核心：主客观相统一，更侧重事实占有。**

刑法上占有重在事实上的支配，占有意思对事实的支配的认定起补充作用。只要求他人对其事实上支配的财物具有概括的、抽象的支配意识，既包括明确的支配意思，也包括潜在的支配意识。具体分述如下：

(1) 只要是在他人的事实支配领域内的财物，即使他人没有现实地握有或监视，也属于他人占有。

高中同学乙到甲家里来玩，为了表示对甲在高中帮助的感谢，乙带了一万来，并在甲不知情的情况下塞到了沙发底下。过几天丙来甲家，偶然发现并拿走了一万元。考虑到甲家为甲事实支配的领域，即使甲没有现实地握有或监视，也构成甲的占有。丙即为盗窃。

典型·出租车遗留财物 须视为出租车司机占有，不能视为遗失物

(2) 虽然表面上处于他人支配领域之外，但存在可以推知由他人事实上支配的状态时，也属于他人占有的财物。

校园骑自己自行车到教学楼下，没上锁，他人将自行车拖走。存在可以推知由他人事实上占有。

小情侣去公园赏樱花，把汽车没锁放在路边，他人将汽车开走并说“今天在路边捡到了一辆汽车”。

【保洁捡到一百多万黄金】甲登机排长队，队伍旁边有一个垃圾桶。甲拎着黄金包就随手放在垃圾桶旁边且没有走一步放一步。保洁人员即将包拎走，后来才发现黄金。不能认为所有人和包有距离了，就失去了占有。一般观念中可推知，财物由行为人所占有。

(3) 在特定场所，所有人、占有人在场的，原则上应认定为所有人、占有人占有。

下课去洗手间，将手机留在座位上。认为手机仍然由所有人占有，即使没有现时随身携带。

【二万六到底谁占有】被害人到银行存钱二万六千，夫妻也去银行办业务。被害人单子填好后，钱放在桌子上。后来想起来时钱就没有了。过程中原来是，一老太太看到了全程，顺手就将钱装在口袋里，后携老伴快速离开。

(4) 主人饲养的具有回到原处能力或习性的宠物，不管宠物处于何处，都应认定为饲主占有。

(5) 即使原占有者丧失了占有，但当该财物转移为建筑物的管理者或者第三者占有时，也应认定为他人占有的财物。

典型·遗留于酒店的东西被后住者拿走 管理者属于事实上的支配，因为酒店的房间具有排他性，即要么是后来住户要么就是酒店工作人员。所以后来者将前面的人的财物拿走，属于盗窃。

【区别】侵占：事实上的支配—排他性

华政教学楼里面忘了带走自己的包。此时华政教学楼的教室属于开放性的，随意出入的。此时财物需要评价为无人占有/原所有人失去占有，此时拿走财物的人只能评价为侵占。

(6) 存款占有归属，存款人占有债权。

(7) 数人共同管理某财物，而且存在上下主从关系时，下位者不占有该财物。此时下位者容易构成盗窃。

保姆偷走主人的东西。仍然认为该财物由主人占有。

销售将店里的衣服直接拿走。仍然认为该财物由店老板所有，所以构成盗窃而不是侵占。

出车站时有人帮忙拿行李拿到车上。只是辅助者，并不占有该财物。

(8) 行为人受他人委托占有某种封缄的包装物时，封缄物整体由受托人占有，但内容物为委托人占有。受托人不法取得封缄物整体的，成立侵占罪；取出其中的内容物的，成立盗窃罪。

(9) 死者的占有主要由三种情况：一是行为人以抢劫故意杀害他人后，当场取得他人财物（抢劫罪）；二是行为人出于其他目的地杀害他人后，产生非法占有他人财物的意思，取得死者的财物；三是无关的第三者从死者身上取得财物。后两种行为认定为侵占罪。

所有权说：故意杀人罪+盗窃罪（遗产继承人所有）

占有说：故意杀人罪+侵占罪（遗产继承人所有，但并不占有。所以此时的财物属于无人占有的状态）

## 四、盗窃罪中需要深入研究的问题

1. 秘密性不是其必要构成要件要素（学说）。

原来：（通说）相对（财产占有者和所有人/财产管理人）的秘密性

（财产占有者和所有人）只有所有人没有看见，其他人在公交车上都看见了/监控拍的清清楚楚小偷的扒窃。此时仍然认为构成盗窃罪。

此时强调秘密性是必要构成要件要素，公然的视为抢夺。

现学说：秘密性不是其必要构成要件要素——重新划分了盗窃罪和抢夺罪之间的界限。

将抢夺罪对象范围限缩，只有行为人对物使用暴力造成人身伤害可能性时才构成抢夺。（其他评价为公然盗窃）如公然抢女生身上的项链。（抢劫：必须对人身有暴力行为）

2. 盗窃公私财物，数额较大：

我国刑法立法是定性+定量。【比较法】美国是立法定性，司法定量。

【延伸】故意中的认识因素包不包含对于罪量的认识：（李翔）对于罪量有认识可能性 否则排除故意。\* 注为“可能性”，不是确定的数额认识。

此时会产生结果：受教育程度越高，注意义务越高，（李翔）这才是公平的。

| 则在盗窃罪中，行为人必须对犯罪数额具有认识可能性。

【农民工到北京培养基地随便摘了两串葡萄价值12万6千块】此时行为具有盗窃性质，但是缺乏对于财物价值的认识，所以出罪。

### 3. 价值：

数额要求或者使用价值要求（身份证等）

价值要求：考虑使用价值及对特定人的价值。

4. 窃取行为是排除他人对财物的支配，建立新的支配关系的过程。窃取的手段与方法没有限制，即便使用了欺骗方法，但如果该欺骗行为并没有使对方基于认识错误处分财产的，仍然成立盗窃罪

5. 多次盗窃，是指二年内三次以上盗窃。

A. “次”应根据客观行为认定，时间、地点、被害人要素

B. 不以每次成立盗窃行为既遂为前提，也不要求每次盗窃行为均成立盗窃罪（更加注重行为人的主观恶性，没有入罪要求）

6. 入户盗窃。合法入户后盗窃的，不宜认定；非法入户，即使入户后才产生盗窃犯意的，也应认定为盗窃罪。

强调入户非法性，没有入罪要求，因为行为上侵害了另外的法益。

5. 携带凶器盗窃的。注意与第267条第2款区别。解释方法论上的问题。

组织未成年人乞讨/违反治安管理活动罪设定入罪门槛时，非常精细。前者因为考虑到乞讨行为本身不具有非法性，所以需要“暴力、胁迫等”要求；后者本身就有非法性，所以没有入罪要求。

没有数额的入罪要求，要找其他的入罪要素，即“携带凶器”。

6. 扒窃要素：公共场所；他人随身携带的财物；值得刑法保护。

行为人主观恶性会更大。

## 五、盗窃罪的认定

1. 盗窃罪与盗窃枪支、弹药、爆炸物罪

2. 盗窃罪与信用卡诈骗罪

【讨论】为什么盗窃信用卡并使用认定为盗窃罪而不认定为信用卡诈骗罪？

法律拟制，不能推广到抢劫、诈骗、抢夺等其他犯罪。

3. 盗窃罪既遂、未遂的认定标准——行为人取得（占有）了财物（行为人的占有与占有人的失去占有一般是并行的），且达到一定数额

结合具体案件本身进行综合评价：

柜台用调包方式偷戒指，但是未出商场被逮住。戒指本身形态容易控制，理解为离开柜台盗窃既遂。

偷电瓶车过程中被发现，被追赶。此处不宜评价为盗窃既遂。

## 六、盗窃罪的死刑废除

1997年刑法

- 盗窃金融机构，数额特别巨大。
- 盗窃珍贵文物，情节特别严重。

刑法修正案八：

- 废除盗窃罪死刑。

## 第三十章 诈骗罪

第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

### 一、概述

1. 概述：以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为

2. 司法解释：

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》

《关于对伪造学生证及贩卖、使用伪造学生证的行为如何处理问题的批复》

《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》

### 二、构成

1. 罪责：故意（非法占有目的）

2. 对象：他人财物

3. 行为：虚构事实或隐瞒真相

### 三、基本问题

1. 诈骗罪的基本构成模式【行为要素】

Step 1 行为人实施欺骗行为（虚构事实或隐瞒真相）

Step 2 对方产生或者继续维持认识错误

Step 3 对方基于认识错误处分（或交付）财产

Step 4 行为人获得或者使第三者获得财产

Step 5 被害人遭受财产损失

2. 欺骗行为

（1）受骗人对行为人所诈称的事项有所怀疑仍然处分财产的，也不影响诈骗罪的成立

（2）在欺骗行为与受骗者处分财产之间，必须介入受骗者的错误认识（因果关系环环相扣）；如果受骗人不是因欺骗行为产生错误认识而处分财产，行为人的行为就不成立诈骗罪（但有成立诈骗未遂的可能性）

【涉及·区别】敲诈勒索：基于恐惧害怕交付还是基于错误认识

（3）欺骗行为的受骗者必须具有处分财产的权限或者处于可以处分财产地位的人，但是不必是财物的所有人或占有人。受骗者还必须具有处分财产的意识。

小朋友被骗说“将妈妈家里的电视机拿来给糖吃”——盗窃罪的间接正犯，因为不具有处分财产的权限也不具有处分财产的意识。

（4）被骗者不限于特定的人



### 3. 处分财产

(1) 处分财产不限于民法意义上的处分财产（即不限于所有权权能之一的处分），而意味着将被害人的财产转移为行为人占有，或者说使行为人或第三人取得被害人的财产。

· 包括在占有基础上的处分；（“不占有”）委托基础上的处分（保姆拿着主人的东西） 【三角诈骗】。

(2) 受骗者处分财产必须有处分权限。

(3) ☆☆☆受骗者处分财产时必须要有处分意识。即认识到自己将某种财产转移给行为人或者第三人占有，但不要去对财产的数量、价格等具有完全的认识。

学者：处分意识可以不要说。考虑到目前电信诈骗的频发，其中被诈骗人有时并没有处分意识。

#### 【案例对比】

(1) 甲在超市购物时，将便宜的照相机价格条形码与贵重照相机条形码予以更换，使店员将贵重照相机以便宜照相机的价格“出售给甲”。店员能够意识到自己在处分照相机，只是对价格有错误认识。甲涉嫌诈骗。

(2) 乙将一个照相机包装盒里的泡沫取出，使一个包装盒里装入两个照相机，然后拿着装有两个照相机的一个包装盒付款，店员只收取一个照相机的货款。店员能够意识到自己在处分照相机，只是对数量有错误认识。乙涉嫌诈骗。

(3) 丙在超市购物时，偷偷将一箱方便面取出几袋，并将一个照相机放在方便面箱子里，然后拿方便面箱子付款，店员收取了一箱方便面的货款。店员没有处分照相机的意识，不能认为被害人在处分财产，进而不能认为丙构成诈骗，只能构成盗窃。\* 注意：此处也有“虚构事实”。所以对于诈骗和盗窃罪而言，即使虚构事实，则不当然地构成诈骗。核心区别在于处分意识。

(4) 丁发现被害人一本名为《考研宝典》的书里面夹有一张“祖国江山一片红”邮票一张，便讨要该书，被害人将该书送给丁，丁将邮票据为己有。被害人并不具有处分邮票的意识，不能认为在处分财产，进而不能认为丁构成诈骗罪，亦不构成盗窃罪，涉嫌侵占罪。

### 4. 获得财产

(1) 积极财产的增加

(2) 消极财产的减少 eg: 免除债务

### 5. 财产损失

(1) 在诈骗不法原因给付物的情况下的处理

【法秩序统一原理】刑法具有保障法的地位，保障其他法律运行，而每个部门法都有相应调整范围。各部门法有一个共同的任务“保证法秩序的统一”。

在民法中，对于不法原因给付，行为人没有办法对于所获的不法财产有所保护。所以有一种观点认为，基于法秩序统一原理，民法都不保护，刑法也不应当保护；另一种观点认为，刑法要保护占有，保护的範圍要比刑法更加宽泛，所以此处不讨论时合法占有还是非法占有（用以解决“黑吃黑”）。

(2) 通过欺骗方式使他人免除非法债务的，不存在财产损失。骗卖淫者免除个人债务不构成诈骗罪；给过卖淫者钱再骗回来，并不构成诈骗罪。

(3) 以欺骗方法取得对方不法占有的自己的所有的财物的，不成立诈骗罪。（本权者恢复权利的行为）

(4) 行为人虽然提供了价格相当的商品，但在告知了事实真相后对方将不付金钱的场合，故意就商品的效能等作虚假陈述，使对方将不付金钱的场合（有所“让利”），故意就商品的

效能等作虚假陈述，使对方误信商品的效能，而接受对方交付的金钱的，**构成**诈骗罪。「作出对方不需要的让利」

(5) 行为人实施欺骗行为，导致受骗者就所交付财产的用途、财产的接受者存在法益关系的认识错误时，即使受骗者没有期待相当给付，也应认为存在财产损失（对财产接受者有期待），行为人的行为成立诈骗罪。诈捐「没有期待相当给付，但是对于财产接受者有期待」

## 四、特殊类型的诈骗罪研究

- 三角诈骗——财产处分人与被害人不同一的情况
- 诉讼欺诈的行为如何定性
- 赌博诈骗——伪装输赢的偶然性（原本没有，现认为须加入具体区分：赌博中核心在于成本性+射幸性，如果根本没有赢的可能，就是诈骗）——对最高人民法院1995.11.6司法解释的质疑：当时按照赌博罪处理，现在看不合适还是按照诈骗处理。
- 无钱饮食、住宿——不能认定为诈骗罪
- 二重买卖——诈骗罪或者侵占罪（所有权转移但约定由出卖人暂时占有一段时间，行为人再卖）

## 五、诈骗罪的认定

- 诈骗罪与其他特殊诈骗罪的关系

266条“本法另有其他规定的，依照其他规定”，由此诈骗罪属于一般犯罪，此外还有金融诈骗、合同诈骗、使用假币、侵犯著作权。

- 诈骗罪与盗窃罪的界限：被害人基于错误认识处分财产
- 向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为——**机器不能被骗**。认定为盗窃，不是诈骗。
- 从没有处分能力的幼儿、精神病患者那里取财——不能认定为诈骗罪，缺乏处分意识、权限、能力等
- 【讨论】以借打手机为名进而非法占有他人手机

【指导案例27号：臧进泉等盗窃、诈骗案】

裁判要点：行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际通过预先植入的计算机程序窃取财物构成犯罪的，以盗窃罪定罪处罚；虚构可供交易的商品或者服务，欺骗他人点击付款链接而骗取财物构成犯罪的，以诈骗罪定罪处罚。相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条

**核心：被害人有没有认识到自己实际在处分财产。行为人只有处分1元的意识没有处分几十万的意识。**

裁判理由：盗窃是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为；诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。对既采取秘密窃取手段又采取欺骗手段非法占有财物行为的定性，应从行为人采取主要手段和被害人有无处分财物意识方面区分盗窃与诈骗如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是秘密窃取诈骗行为只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付财物的，就应当认定为盗窃；如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是诈骗，被害人基于错误认识而“自愿”交付财物，盗窃行为只是辅助手段的，就应当认定为诈骗。

# 第三十一章 抢夺罪

## 一、概述

1. 概述：指以非法占有为目的，公然夺取公司财物，数额较大或者多次抢夺的行为

2. 司法解释

《关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于审理抢劫案件具体适用法律若干问题的解释》

## 二、构成

1. 行为：公然强行将他人控制下的财物夺取据为己有，数额较大或多次抢夺

(1) 公然：具有相对性。

2. 对象：公司财务（不包括特定物品）

3. 罪责：故意

## 三、抢夺罪的认定问题

· 暴力的指向——物

不能限定在“夺”的要素上，进而不能觉得被害人具有紧密占有关系。而应该强调被害人对于财物有占有意识即可。被害人与财物具有紧密占有关系是一种抢夺，不是全部。

【区别】抢夺罪&抢劫罪。前者是针对物的有形力，后者是针对人。

· 利用机动车辆抢劫的认定 飞车抢夺

（李翔）创设性司法解释不具有约束力，不然立法干嘛

最高院当时针对广东飞车抢夺的司法解释具有创设性

· 携带凶器抢夺的认定（转化为抢劫罪）

· 上述凶器的认定：（1）在性质上就可以被评价为凶器 管制刀具（2）在用法上可以被评价为凶器 板砖（性质属于建筑材料）

· 上述携带的认定：行为人为抢夺时候使用而携带，或者在抢夺时意识到自己携带（不是客观状态）。而不是仅仅认定为“携带”的客观状态。

## 四、几种需要反思的表述

· “抢夺的乘人不备”问题：是一种表现形式，不是唯一表现形式

· “抢夺的公然性”的问题：是相对的，不要求第三人在场。

· 抢夺罪与抢劫罪关系问题，其中“成立抢夺罪，只能是对物的暴力行为，不能包涵对人的暴力行为”的问题：不能单纯认为只要对人暴力就是抢劫，因为抢劫的暴力有程度性要求。

· 关于“携带凶器盗窃”转化为“携带凶器抢夺”问题：前者为盗窃罪，后者转化为抢劫罪

· 甲使乙手持凶器与自己同行，甲实施抢夺A财物，如何处理？（见携带的认定）

# 第三十二章 侵占罪

## 一、概述

1. 概述：指以非法占有为目的，将代为保管的数额较大的他人财物占为己有，拒不退还或者将他人的遗忘物、埋藏物占为己有，数额较大，拒不交出的行为

## 二、构成

1. 行为：已然持有（合法持有）+非法占有

【区别】和盗窃罪最大的区别：财物处于行为人的占有

2. 对象：代为保管的他人之物，埋藏物、遗忘物

3. 罪责：故意

## 三、侵占罪的基本问题

1. 【普通侵占】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，或者【遗忘物/埋藏物侵占——侵占脱离占有物】将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的行为。包括普通侵占和侵占脱离占有物。

(1) 普通侵占一般发生在熟人之间，所以设置为“告诉才处理”

(2) 侵占脱离占有物

· 【区别】遗失物 vs 遗忘物——一般以财物所有人的记忆力作为判断标准。

遗失物无法想起；遗忘物可以想起。

区分目的：限制处罚范围。遗失物不考虑刑法处罚。

· (李翔) 有无必要对遗忘物和遗失物进行区别？

不论是否存在委托关系，只要非行为人所有，就要受到刑法处罚：

宽泛遗忘物定义：非经他人本意而失去控制，偶然（即不是基于委托关系）由行为人占有或者占有人不明的财物。

底层逻辑：君子社会。刑法理论根据：评价行为人行为应当从行为人角度分析，不能从被害人角度分析记忆力——行为人是否会定罪，完全取决于被害人记忆力的好坏。

· 埋藏物：埋藏于地下，所有人不明或应由国家所有的财物。

(3) “拒不退还，拒不交出”：说明要求权利人至少有一次权利的主张过程。限制了处罚范围

“非法占为己有”与“拒不退还”的关系：后者是对前者的强调或者补充说明，即将自己占有的他人财物变为自己所有的财物。

【例外】如果行为人将财产处分——遵从财物的用法，例如出卖、赠予、消费、抵偿债务等，就表明其“非法占为己有”。如果单纯毁坏则不能成立本罪。| 即如果代为保管的财物不可替代，而作为保管人以所有人自居消费使用。此时可以认定为：明知道消费后财物灭失，直接认定为“非法占为己有”。

· “拒”的理解：不可将行政权直接用司法权替代。

2. 代为保管——事实上的支配和法律上的支配，以财物所有人与行为人之间存在委托关系为前提

3. 基于不法原因而委托给付的财物，能否成为本罪的对象。

4. 窝藏或者代为销售的赃物能否成为侵占罪的对象



5. 侵占行为的理解——取得行为

## 四、侵占罪疑难问题探讨

1. 侵占罪与盗窃罪的区别——判断财物由谁占有，是否脱离占有

2. 行为人认识错误

例如，行为人将他人占有的财物误认为他人的遗忘物而非法占为己有；本来是遗忘物，行为人以为是他人占有的财物而非法占为己有

3. 由于侵占罪的对象难以排除国家、集体所有的财产，立法上的亲告罪设置似有疑问：**告诉才处理包括控告与起诉。**